

1500594-55.2022.8.26.0361
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Davi de Castro Pereira Rio
Comarca: Mogi das Cruzes
Foro: Foro de Mogi das Cruzes
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 30/08/2022
... flagrante.

Neste sentido:

"APELAÇÕES. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. REGIME FECHADO. IMPROVIMENTO DOS RECURSOS DEFENSIVOS. 1. As autorias e a materialidade dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico restaram devidamente comprovadas, não só porque a substância ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Mogi das Cruzes
Foro de Mogi das Cruzes
2ª Vara Criminal
Avenida Valentina de Mello Freire Borenstein, 331, Mogi das Cruzes - SP - cep 08735-270

1500594-55.2022.8.26.0361 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1500594-55.2022.8.26.0361
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
MARCELINO ELIAS DOS SANTOS e outro

Juiz de Direito: Dr. Davi de Castro Pereira Rio

VISTOS.

MARCELINO ELIAS DOS SANTOS e JAILSON SANTANA GOMES, devidamente qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incurso nas penas cominadas no artigo 33, caput e § 1º, inciso II, e artigo 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06.

Segundo relata a denúncia, no dia 03 de fevereiro de 2022, por volta das 06hs45min, na Rua Santo Tirolli, nº 812, Mogi das Cruzes/SP, MARCELINO ELIAS DOS SANTOS e JAILSON SANTANA GOMES, agindo em concurso e com unidade de desígnios, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de

mercancia, cultivaram 20 (vinte) exemplares da planta Cannabis Sativa L, contendo 13,5 quilogramas, plantas que se constituem em matéria-prima para a preparação de drogas, substância entorpecente listada na Portaria nº 344/1998, SVS/MS, Lista F2 (Lista de substâncias entorpecentes de uso proscrito no Brasil).

Consta, ainda, que, em data indeterminada até o dia 03 de fevereiro de 2022, por volta das 06hs45min, nesta cidade de Mogi das Cruzes/SP, MARCELINO ELIAS DOS SANTOS e JAILSON SANTANA GOMES associaram-se para o fim de praticar reiteradamente o delito de tráfico de drogas.

Recebida a denúncia (fls. 96/97), os réus foram regularmente citados (fls. 115 e 117) e apresentaram respostas escritas à acusação (fls. 144).

Em audiência de instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação, tendo sido então decretada a revelia dos acusados, nos termos do artigo 367 do Código de Processo Penal (fls. 207).

Encerrada a fase de instrução, a i. representante do Ministério Público, em sede de alegações finais, pleiteou a condenação dos acusados, sustentando a comprovação dos fatos narrados na denúncia.

A i. Defesa do acusado Marcelino Elias dos Santos apresentou alegações finais às fls. 208/212, reiterada às fls. 241/242, oportunidade em que pleiteou a absolvição do réu, alegando que o acusado não concorreu para a prática do delito ou a inexistência de prova suficiente nos autos para ensejar a condenação. Subsidiariamente requereu a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o delito previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/06, a fixação da pena-base no mínimo legal e de regime menos gravoso para início de cumprimento de pena, o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, bem como o direito de recorrer em liberdade.

Pela Defesa do réu Jailson Santana Gomes foi apresentada alegações finais às fls. 225/237, na qual se requereu a absolvição do acusado por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteou a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, a imposição de regime menos gravoso para início de cumprimento de pena com a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, bem como o direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.
DECIDO.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade dos delitos ficou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 01/03, pelo boletim de ocorrência de fls. 11/14, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 17, pelo laudo de constatação de fls. 19/21, pelo laudo pericial de fls. 121/128, pelo laudo de exame químico-toxicológico de fls. 129/131, bem como pela prova oral produzida em Juízo.

A autoria dos delitos é incontroversa.

Os acusados deixaram de comparecer em Juízo para apresentar as suas versões dos fatos, razão pela qual foi decretada a revelia.

Em que pese a ausência da versão dos réus acerca dos fatos, as provas produzidas em Juízo são uníssonas em comprovar os fatos narrados na denúncia.

No caso em tela, as provas produzidas em Juízo permitem de maneira segura concluir

pela prática dos delitos de tráfico e associação para o tráfico em relação aos réus.

O policial civil Cayo Bassalo Alvares da Silva disse que a prisão dos réus decorreu de investigação policial prévia onde se constatou movimentação típica de tráfico de drogas na residência em que eles foram presos. Contou que em cumprimento de mandado de busca e apreensão lograram deter os acusados em flagrante. Disse que ao adentrar na residência os acusados tentaram fugir pelos fundos do imóvel, porém foram presos por policiais que cercavam o imóvel. Contou que no quintal do imóvel havia plantação de "maconha" e no terreno do outro lado da rua também havia mais um pé de maconha, sendo apreendido no local também uma balança de precisão. Disse que os acusados alegaram que todo o entorpecente era para consumo próprio.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial civil Rafael de Oliveira Santos, ressaltando apenas não se lembrar de ter sido apreendido apetrechos comumente utilizados para a traficância.

Deveras, nada desautoriza o depoimento prestado pelos policiais, no caso concreto.

Ao contrário, as testemunhas, ouvidas em juízo e na fase extraprocessual, apresentaram versão coerente e detalhada dos fatos.

Destaco, ademais, que não há motivos para distinguir a validade do depoimento de policiais das demais provas orais produzidas em juízo, porque eles, como quaisquer testemunhas, depõem sob compromisso, devendo ser presumida, por isso, a veracidade de suas afirmações, até que se demonstre cabalmente o contrário.

Neste sentido é o entendimento do i. Desembargador Hermann Herschander:

"Nada impede que policiais, como quaisquer outras pessoas, testemunhem sobre fatos de que tiveram conhecimento. Repele-se a preconceituosa objeção que procura inquinar aprioristicamente os depoimentos prestados por policiais, como se estes, em princípio, não fossem dignos de credibilidade. Seria impensável que o Estado, sem qualquer motivo concreto, desprezasse os depoimentos daqueles que ele mesmo constituiu e a quem confiou a tarefa de velar pela segurança pública. Inexistindo qualquer indício de que os policiais tivessem algum interesse em incriminar falsamente o apelante, seus depoimentos, seguros e coesos, merecem crédito." (Apelação Criminal nº. 0015247-38.2012.8.26.0604, 14ª Câmara de Direito Criminal, j. 03 de julho de 2014, Des. Rel. Herman Herschander)"

Inicialmente, é de se destacar que a prisão dos acusados somente foi efetivada em razão de decisão que determinou o cumprimento do mandado de busca e apreensão nos autos nº 1500246-37.2022.8.26.0361-1ª Vara Criminal local.

No caso em tela, as provas produzidas em Juízo nos autos foram cristalinas e indubitáveis ao comprovar os delitos narrados na denúncia, de maneira que o bom trabalho de investigação realizado pelos policiais, tornam irrefutáveis as versões por eles apresentadas em Juízo.

Com efeito, de forma coesa e harmônica os policiais relataram que realizaram investigação prévia no imóvel ocupado pelos acusados, constatando movimentação típica de tráfico de drogas, de modo que em cumprimento de mandado de busca e apreensão lograram êxito na prisão dos acusados que ao visualizarem a presença de policiais tentaram empreender fuga.

A versão sustentada pela defesa do acusado Marcelino de que estava no local apenas pernoitando, não merece prosperar, uma vez que não encontra ressonância com as demais provas produzidas em Juízo. É de se ressaltar que sequer o acusado compareceu em Juízo para apresentar sua versão acerca dos fatos, da mesma forma o

corréu Jailson, que poderia sustentar essa versão, também não compareceu.

Deste modo, não trouxeram qualquer elemento que pudesse infirmar o já tão desfavorável panorama processual para si, apresentando apenas versões vagas e desprovidas de um mínimo de credibilidade.

A situação flagrancial, a grande quantidade do entorpecente apreendido ainda em plantio, bem como de apetrecho utilizado comumente para a prática do tráfico de drogas (balança de precisão), conforme auto de exibição e apreensão, as circunstâncias em que foram presos em virtude de cumprimento de mandado de busca e apreensão, evidenciam a prática de mercancia ilícita pelos réus.

Ressalto que, para a configuração do delito de tráfico de drogas, basta a finalidade de guardar, manter em depósito, trazer consigo, fornecer, ainda que gratuitamente, a substância, para caracterizar o crime em questão.

Destaco que as provas são seguras nesse sentido e ficaram comprovadas não só pelos depoimentos prestados, como também pela quantidade de drogas apreendidas.

Assim, no caso em tela, fica afastada a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas, uma vez que os elementos são claros no sentido de que o réu praticava o comércio de drogas.

Além disso, o fato de serem usuários de entorpecente, como alegam, por si só, não altera o conjunto probatório, já que é notório o fato de que muitos usuários acabam comercializando entorpecentes justamente para manter o vício.

Outrossim, ficou sobejamente comprovada a acusação de associação para o tráfico.

Com efeito, o delito de associação para o tráfico exige para a sua consumação a estabilidade das relações entre os agentes, devendo existir um caráter duradouro e estável, ajustados para a finalidade de comercialização de entorpecentes.

Como esclarece Guilherme de Souza Nucci, “a advertência feita no tipo penal (reiteradamente ou não) quer apenas significar que não há necessidade de haver habitualidade, ou seja, não se demanda o cometimento reiterado das figuras típicas descritas nos arts. 33 e 34, bastando a associação com o fim de cometê-los” (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Vol. 1. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 414).

As provas são seguras acerca do vínculo associativo dos réus e ficaram comprovadas não só pelos depoimentos prestados, como também pela quantidade de drogas apreendidas, além da apreensão de apetrecho comumente utilizado para o tráfico.

Vale ressaltar, como dito, que a prisão dos réus somente foi possível em virtude de cumprimento de busca e apreensão deferida judicialmente, a qual a autoridade policial representou em razão de diligência policial que constatou movimentação típica de tráfico de drogas na residência em que os acusados foram presos.

Dessa forma, comprovado que os acusados estavam associados em data muito anterior à prisão em flagrante.

Neste sentido:

“APELAÇÕES. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. REGIME FECHADO. IMPROVIMENTO DOS RECURSOS DEFENSIVOS. 1. As autorias e a materialidade dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico restaram devidamente comprovadas, não só porque a substância entorpecente foi encontrada na posse de um dos réus, como também porque

restou comprovado o vínculo associativo entre ambos os dois para fins da prática, reiterada ou não, do comércio espúrio, mercê de provas idôneas e suficientes para as suas responsabilizações. 2. Depoimentos dos policiais militares harmônicos e uníssonos no sentido da responsabilização criminal dos réus. Validade dos seus depoimentos, mormente quando submetidos ao crivo do contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o crime. 3. Dosimetria da pena fixada de modo escorreito. 4. Mantém-se o regime inicial de cumprimento de pena no fechado, medida esta estabelecida em perfeita harmonia com o tratamento diferenciado e mais rígido conferido pela própria Constituição Federal aos crimes hediondos e equiparados (art. 5º, XLIII), não cumprindo ao Poder Judiciário analisar a conveniência e adequação da política criminal do seu tratamento, matéria reservada ao Poder Legislativo, órgão constitucionalmente competente para tanto. Ademais, "in casu", o regime fixado continua sendo o fechado, mercê da pena imposta aos réus, nos termos do art. 33, § 2º, a, do Código Penal. 5. Improvimento dos recursos das defesas. (TJ-SP - APL: 00015180220118260370 SP 0001518-02.2011.8.26.0370, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 14/04/2014, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 15/04/2014)".

Ainda, como muito bem ressaltado pelo representante do Ministério Público "Por óbvio, as circunstâncias do caso concreto indicam que os denunciados mantinham vínculo estável, na medida em que a sementeira e o cultivo de tais plantas exige a prática reiterada de atos para que a cultura prospere, o que revela a existência de associação para o tráfico de drogas previamente formada".

Assim, constata-se que não houve o mero concurso de agentes, mas sim evidenciadas a estabilidade e a permanência necessárias para a configuração do delito de associação.

Dessa forma, provadas a autoria e a materialidade a condenação dos acusados pelo delito de tráfico de drogas e de associação para o tráfico é medida de rigor.

Passo, então, à fixação da pena.

Considerando o disposto no artigo 59 do Código Penal, o qual indica todos os parâmetros para a fixação da pena-base, levando-se em conta as circunstâncias do crime, em especial a grande quantidade de entorpecente (13,5 quilogramas), fixo a pena-base aumentada em um sexto, vale dizer, pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

No entanto, com relação ao crime previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/06, verifico que não há motivos concretos para ensejar a fixação acima do mínimo legal.

Na segunda fase de fixação da pena não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Quanto à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, verifico que os réus não preenchem os requisitos exigidos, uma vez que a associação criminosa na prática do tráfico de drogas, demonstram que possuem ligação com atividades criminosas.

Não há como se crer que os acusados cultivavam grande quantidade de entorpecente atuando de forma associada, sem que tivessem qualquer tipo de vínculo com organização criminosa.

Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça "Configurado o crime de associação para o tráfico, fica vedada a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, por expressa determinação legal" (HC 349.8378/SP, rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, 5ª Turma, DJ 03/05/2016).

Ademais, o Supremo Tribunal Federal já assentou que “a conduta social do réu, o concurso de agentes, a quantidade e a natureza do entorpecente, os apetrechos utilizados e as circunstâncias em que a droga foi apreendida podem constituir o amparo probatório para o magistrado reconhecer a dedicação do réu à atividade criminosa” (RHC nº 116.926/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 4/9/13).

Incabível, pois, a redução prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Sobre o tema, cumpre trazer à baila brilhante lição sobre o tema, em acórdão da lavra do i. Desembargador Geraldo Wholers (Apelação nº 0427092-39.2010.8.26.0000 – 3ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo):

“O propósito do legislador, certamente, não foi favorecer os traficantes de alto coturno. A mens legis da Lei nº 11.343/06 há de ter tido em vista, primordialmente, fornecedores ocasionais, que não denotam perseverança criminosa, hábito delinquencial ou gravíssimo comprometimento para a ordem social, a paz coletiva e a saúde da população em geral, virtudes certamente irreconhecíveis no imperdoável traficante de drogas que persevera nessa senda. Tanto, aliás, que o citado art. 33, § 4o, contém expressa referência, para fins de merecimento da redução condescendente, à exigência de que o agente “não se dedique às atividades criminosas”. Sabe-se que em termos repressivos o ditame constitucional é o de desestimular com energia o comércio ilegal de drogas; logo, o benefício trazido pela nova lei de regência, editada sob o mote de tornar mais rigoroso o tratamento penal que incide sobre o traficante, conflita, quando aplicado de modo indiscriminado, com a Constituição da República. Há, além da quebra do princípio de isonomia entre os condenados por outros crimes (especialmente pelos classificados como igualmente hediondos) e os condenados por tráfico de drogas, uma violação às disposições constitucionais e aos tratados internacionais que obrigam o Poder Público brasileiro à repressão efetiva do narcotráfico. A inteligência útil e legítima da norma sob análise só pode ser feita à luz da Carta Política, e nesse passo se conclui que a mercê foi estabelecida para dar solução excepcional a situações excepcionais. No âmbito desta Colenda Câmara, registrou o preclaro DES. LUIZ ANTÔNIO CARDOSO por ocasião do julgamento da Apelação Criminal nº 990.09.111160-0 (Comarca de Lucélia, j. em 25 de maio de 2010), que “essa causa de redução da pena deve incidir na excepcionalidade, em situações específicas, próprias, quando patente que o tráfico apurado cuidou-se apenas de um desvio na vida do réu, e não de uma contumácia, estilo, repetição de fato análogo, de uma rotina de proceder”. A lei atual trouxe tratamento distinto para quem oferece droga a pessoa de seu relacionamento sem objetivo de lucro - a rigor, traficante de entorpecentes: § 3o do mesmo artigo 33. Ora, também se reserva tratamento diferenciado no § 4o, pois o redutor se dirige a quem comete uma das condutas puníveis constantes do caput ou do § 1o do artigo 33 quando o agente atua sem ter o lucro por meta, sem intuito de comércio, sem adotar a odiosa e desagregadora propagação narcótica como meio de vida. É assim que se deve considerar a exigência de “não se dedicar às atividades criminosas” (terceira figura dos pressupostos indispensáveis à concessão da benesse), porque quem procura obter vantagem financeira através do mercadejo de substância clandestina se propõe, claro, a exercer atividade criminosa: presta o torpe serviço para alguém, faz a deplorável intermediação para alguém, busca aumentar os recursos ilícitos de grupos ou organizações formadas à margem da lei para custear investidas delituosas n'outros setores do submundo. Convenhamos ser fenômeno de extrema raridade o traficante que age solitariamente... Se se der outra interpretação ao dispositivo em apreço, de forma a alcançar todo e qualquer agente que preencha os demais requisitos, haverá incontornável discrepância com outras normas da mesma Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, como, por exemplo, a descrição típica de seu artigo 37 (mero informante)”.

Em razão da ausência de informações suficientes acerca das condições financeiras

dos réus, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal.

Ressalto que não há qualquer inconstitucionalidade no tipo legal do tráfico, ou mesmo em seu preceito secundário, uma vez que a própria Constituição Federal estabelece um maior rigor contra os crimes hediondos e aos equiparados a estes.

Tratando-se de crime equiparado a hediondo, deverão os réus iniciar o cumprimento da pena em regime fechado, nos termos do que dispõe o art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, com a redação dada pela Lei nº 11.464/07, sendo o regime fechado o único compatível para atender as finalidades de prevenção e repressão da pena.

Neste ponto, cumpre trazer à baila brilhante lição sobre o tema, em acórdão da lavra o i. Desembargador José Damião Pinheiro Machado Cogan (Apelação nº 0014063-92.2015 - 5ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo):

“O regime inicial fechado é o único adequado em face do Princípio da Suficiência Penal, mormente porque se trata de delito equiparado a hediondo, que enseja maior repressão e reprovação, por ser verdadeiro flagelo da sociedade hodiernamente. Outro regime seria insuficiente para a reprovação de tráfico dessa monta. Anote-se que o regime aberto é incompatível com a infração de tráfico de drogas, que se tornou uma das grandes pragas modernas a atormentar a sociedade, mormente no Brasil, antes país de passagem da droga para o exterior, sendo hoje um dos países com grande número de traficantes, passando a droga a ser utilizada aqui, sendo exemplo disso que 70% dos processos em julgamento nas sessões ordinárias dessa E. Câmara, sempre em número superior a 500 feitos, são referentes a tráfico de drogas. Assim, transformando-se o tráfico num dos verdadeiros cancros da atualidade, envolvendo jovens e desagregando famílias, deve ele ser combatido com rigor, rigor este que só se encontra presente na imposição do regime fechado para o traficante. Ademais, não pode o julgador ter seu olhar voltado para as estrelas, mas deve ser homem do seu tempo, que não ignora que a leniência com o tráfico destrói famílias, jogando usuários e viciados na sarjeta, bem como incrementa roubos, latrocínios, furtos e homicídios”.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos por força do art. 44, caput, da Lei nº 11.343/06, bem como pelo fato de que não estão preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos do art. 44 do CP.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para declarar MARCELINO ELIAS DOS SANTOS e JAILSON SANTANA GOMES, como incurso no artigo 33, caput e § 1º, inciso II, e artigo 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, CONDENANDO-OS ao cumprimento de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1283 (um mil, duzentos e oitenta e três) dias-multa, cada qual fixado no mínimo legal, reajustado desde a prática delituosa.

Defiro o recurso em liberdade

Oportunamente, expeça-se guia de recolhimento definitiva e mandado de prisão.

Por fim, determino a destruição dos objetos apreendidos, bem como a incineração dos entorpecentes.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Mogi das Cruzes, 30 de agosto de 2022.